

1501724-79.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... policiais por alta incidência de tráfico de drogas, quatro indivíduos correram sentido contrário à viatura. Abordaram LUCIANO, já investigado pela prática de tráfico de drogas naquela comunidade. O acusado negou que residisse naquela comunidade, mas outros populares indicaram de forma reservada onde seria (de fato) a casa em que o réu morava. Em poder de LUCIANO, nenhum ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501724-79.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2305075/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 125/2021 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2305075/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO DIAS BARBOSA

Contr. nº 2021/001188

Aos 08 de novembro de 2022, às 14:20 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Ausente o réu LUCIANO DIAS BARBOSA (revelia fl. 175). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PCs JOSE VICENTE FESSEL e MAURO TEIXEIRA NUNES.

INICIADOS OS TRABALHOS, pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PCs Fessel e Mauro) foram gravados em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).1. LUCIANO DIAS BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processados como

incurso no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 9 de novembro de 2021, por volta das 10 horas, na rua Reverendo Misael Bozom Penteado, Barraco 5, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca, LUCIANO tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 22 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 27,51g; e 48 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 14,57g (cf. AEA de fls. 7, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 93/95 e fotografias de fls.8/9), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls.5/6). É da inicial que policiais civis fizeram uma incursão nos pontos de vendas de drogas da comunidade, quando visualizaram LUCIANO, já conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico, em fuga. O acusado foi alcançado e abordado. Consentiu, ademais, que sua residência fosse vistoriada. No local, junto ao galinheiro, os policiais localizaram as porções de drogas já discriminadas, que o acusado tinha em depósito - conforme admitiu - para entregar a terceiros. 2. O processo teve trâmite regular, cf. fls. 108, 117, 119/120, 135 e 152/153. 3. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 5/6, depoimentos colhidos e, especialmente, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 7, fotografia de fls. 8, e laudos de constatação de fls. 22/33 e toxicológico de fls. 93/95. 4. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os policiais civis Mauro e José Vicente explicaram que estavam em patrulhamento de rotina e após adentrarem a comunidade, já conhecida nos meios policiais por alta incidência de tráfico de drogas, quatro indivíduos correram sentido contrário à viatura. Abordaram LUCIANO, já investigado pela prática de tráfico de drogas naquela comunidade. O acusado negou que residisse naquela comunidade, mas outros populares indicaram de forma reservada onde seria (de fato) a casa em que o réu morava. Em poder de LUCIANO, nenhum objeto ilícito foi encontrado, mas ele tinha uma chave do portão de uma das casas. Após a abertura do local, voltou atrás e assumiu que se tratava de sua residência, permitindo o acesso dos policiais ao seu interior. Contaram que foi localizado, próximo a um galinheiro de 22 eppendorfs de cocaína e outras 44 porções de ser crack. Relataram que Luciano reside sozinho e questionado assumiu informalmente a posse das drogas. Em Juízo, o policial José Vicente informou que LUCIANO inicialmente negou que residisse no local. Moradores acabaram informando que o réu residia na casa defronte onde ocorreu a abordagem. A chave que o denunciado possuía correspondia a essa casa. Ele acabou admitindo a traficância. As drogas foram encontradas junto ao galinheiro, no quintal. Em Juízo, o policial Mauro explicou que o réu autorizou a entrada dos policiais, assim que se descobriu onde ele morava. Na audiência de custódia, o réu negou qualquer abuso por parte dos policiais. Já no interrogatório policial, LUCIANO optou pelo silêncio. Fazendo-se revel em Juízo, não refutou a imputação. Assim, ficou evidente nos depoimentos dos servidores públicos que a droga apreendida pertencia, de fato, ao acusado. Não há razão para duvidar do que disseram. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais, forte no entendimento de que seria um contrassenso acometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). Em conclusão, a condenação é de rigor. 5. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu não possui antecedentes desabonadores (fls. 109). 6. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal, condenando-se o réu como incurso no art. 33 da LD.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). LUCIANO DIAS BARBOSA foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 9 de novembro de 2021, por volta das 10 horas, na rua Reverendo Misael Bozom Penteado, Barraco 5, bairro Novo Horizonte, cidade e comarca de Piracicaba, teria em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 22 (vinte e dois) eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 27,51 gramas; e 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 14,57 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a inicial acusatória, policiais civis

fizeram uma incursão nos pontos de venda de drogas na comunidade, quando visualizaram o réu em fuga. Ele então foi alcançado e abordado. Ainda Segundo a denúncia, consentiu para que sua residência fosse vistoriada. No local, junto a um galinheiro, os policiais encontraram as drogas mencionadas, que o réu admitiu que entregaria a terceiros. Ocorre, no entanto, que a ação penal deve ser julgada improcedente em razão da ausência de provas válidas. De fato, ouvidos ao longo da persecução penal, os policiais civis relataram que o réu foi abordado após tentar empreender fuga. Após revista pessoal, nada foi encontrado em seu poder. Inicialmente ele disse que não morava na comunidade, o que teria sido desmentido por populares, que indicaram seu correto endereço. Após certa resistência, o réu teria consentido para que os policiais realizassem as buscas, que culminaram na apreensão das drogas. Dessa forma, restou clara a violação ao que dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que trata da garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar, pois os policiais ingressaram na suposta residência do acusado sem autorização judicial, alegando que houve autorização. Porém, a autorização não está comprovada nos autos, não bastando para tanto a simples palavra dos agentes policiais. Isso porque não é crível que alguém que guarde substância entorpecente em casa vá permitir que agentes do Estado ali entrem, sabendo que isso vai representar sua prisão. E segundo porque as regras de experiência indicam que a pessoa abordada, na verdade, não tem qualquer opção a não ser autorizar o ingresso, de sorte que não há como falar em voluntariedade. Na verdade, a própria narrativa dos policiais civis deixa transparecer que o acusado não consentiu com a busca. Afinal, inicialmente indicou endereço errado, o que demonstra certa resistência. De toda forma, a partir do julgamento do paradigmático HC 598.051/SP, o E. STJ estabeleceu ser ônus estatal comprovar a voluntariedade do consentimento, fixando, dentre outros, os seguintes pontos: a-) "Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva"; b-) "As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente"; c-) "São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça"; d-) "A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor". E no caso em apreço, verifica-se que: a-) não existia uma emergência que justificasse a busca naquele momento; b-) o contexto fático anterior não trazia indícios de que o réu guardava droga em sua casa, muito pelo contrário, ele foi abordado na via pública,

sem nada de ilícito consigo; c-) não há prova audiovisual do consentimento do réu. Além disso, ainda que o réu tivesse realmente empreendido fuga, isso não justificaria a diligência: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SEM PRÉVIA DENÚNCIA ANÔNIMA OU INVESTIGAÇÕES. FUGA DE INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local associada ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência"). Precedentes: RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020; RHC 83.501/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 05/04/2018; RESp 1.593.028/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020; AgInt no HC 530.272/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020. 4. No caso concreto, a leitura do Boletim de Ocorrência revela que os policiais adentraram a residência do Paciente sem sua prévia permissão e sem prévia autorização judicial, baseados apenas no fato de que, ao avistar a viatura policial em patrulhamento, o paciente correu para dentro de sua residência. Não houve sequer denúncia anônima imputando ao paciente qualquer tipo de cometimento de crime, muito menos investigações prévias por parte da autoridade policial para amparar suspeitas de que, no local, eram armazenados entorpecentes. 5. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, a prova colhida na ocasião deve ser considerada ilícita. 6. Não existindo indicação de provas independentes da materialidade do delito, a justificar a continuidade da ação penal, deve ser ela trancada. 7. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento". (STJ - AgRg no HC 665.373/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). Dessa forma, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, não existindo prova da legalidade do ato praticado pelos policiais civis, deve a apreensão ser declarada nula e o acusado absolvido. Isso porque, sendo ilícita a conduta em sua origem, pouco importa que depois os policiais tenham realmente encontrado a droga na casa do réu, pois essa prova restou contaminada pela ilegalidade. De fato, o artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, conceitua a prova ilícita como aquela que é produzida em desacordo com normas constitucionais ou legais, que é o que aconteceu no caso em apreço. E aqui foi violada norma constitucional que trata da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, CF). Por consequência, considerando, ainda, os artigos 157, § 1º, e 573, § 1º, do CPP, todas as provas dali decorrentes também devem ser consideradas ilícitas (por derivação). Afinal, retirando-se a ação ilegal, simplesmente não ocorreria a apreensão da substância entorpecente. Não haveria, por conseguinte denúncia e início da ação penal. Assim, tudo está relacionado à

ilegalidade ocorrida na origem, de modo que, uma vez seja esta reconhecida, nenhuma outra prova válida existe contra o réu, o qual deverá ser absolvido, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja acolhida a tese da ilegalidade, a Defesa requer a absolvição do acusado pela insuficiência probatória, tendo em vista que a prova produzida contra ele se resume ao que foi dito pelos policiais civis, que não podem ser considerados como testemunhas totalmente isentas. Não se quer dizer que os agentes policiais mentiram, mas apenas que não há como não considerar que seus depoimentos estão contaminados pela atuação que tiveram na apuração dos fatos. Assim, ainda que não estejam impedidos de depor, certo é que seus testemunhos devem ser recebidos com cautela, sobretudo no momento de se conferir o devido valor probatório. Não é por outra razão que em diversas ocasiões já se decidiu pela impossibilidade de se fundamentar uma condenação apenas com base na palavra dos responsáveis pela persecução penal: “As palavras dos policiais merecem credibilidade, mas não basta o título (exercício da função de policial). Há necessidade de que estas tenham apoio em evidências circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável”. (TJSP - 7ª Câ. - Ap. Cr. n. 1.465.651/6 - Com. de Campinas - j. 19/5/2005 - v.u.). No mesmo trilho ensina o professor Gustavo Henrique Badaró (os destaques são nossos): “Quanto aos depoimentos dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do art. 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma corrente intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelo simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranha aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por eles investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se mostrem harmônicos entre si”. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). E, no caso sob análise, para além dos depoimentos dos agentes integrantes aos quadros da segurança pública, nenhuma outra prova foi produzida. Assim, as provas produzidas contra o réu são bem precárias, ainda mais considerando o crime que lhe é atribuído, equiparado a hediondo. De mais a mais, cumpre registrar que quanto mais se dá crédito a esse tipo de prova – depoimento de policiais -, mais se incentiva a precariedade de investigações, o que pode dar azo a abusos e manipulações. Dessa forma, por tudo que foi exposto, sendo frágil o conjunto probatório, a Defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso, no entanto, o entendimento de Vossa Excelência seja diverso, em caso de condenação pelo crime mais grave narrado na denúncia, requer-se a fixação da pena no mínimo legal, considerando que não houve apreensão significativa de entorpecente. Também é o caso de aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O acusado é absolutamente primário. Possui em seu desfavor apenas um processo e em andamento, por fato posterior. Ocorre, no entanto, que esse dado não pode ser utilizado em seu prejuízo, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” (Tema 1139). No mesmo sentido a jurisprudência do STF: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA

APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em "investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional" (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento" (STF - HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018). Além do mais, qualquer análise sobre possível "dedicação a atividades criminosas" deve ser feita à luz da vida anteacta, não podendo ser considerado, portanto, um fato posterior. Assim, por todos esses motivos, de rigor a aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que possibilita, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação do regime aberto para o caso de conversão. Caso não seja aplicada a minorante, pugna-se para que, ao menos, seja fixado o regime semiaberto, compatível com a primariedade do réu. Por fim, ausentes os requisitos da prisão preventiva, requer-se seja autorizado ao acusado que apele em liberdade, se assim desejar. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,
LUCIANO DIAS BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 9 de novembro de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Reverendo Misael Bozom Penteado, barraco 05, bairro Novo Horizonte, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 22 "eppendorfs" contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 27,51g e 48 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 14,57g (cf. AEA de fls. 7, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 93/95 e fotografias de fls. 8/9), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls.5/6).

Narra a denúncia que os policiais civis fizeram uma incursão nos pontos de vendas de drogas da comunidade e visualizaram o réu, já conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico, em fuga. Ele foi alcançado e abordado. Consentiu, ademais, que sua residência fosse vistoriada. No local, junto ao galinheiro, os policiais localizaram as porções de drogas já discriminadas, que o réu tinha em depósito - conforme admitiu - para entregar a terceiros.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 116). Defesa preliminar apresentada às fls. 119/120. Após, a denúncia foi recebida (fls. 135) e o réu foi citado (fls. 147).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum. O réu não foi interrogado, pois revel.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa arguiu ilicitude da ação dos policiais e pediu a absolvição, sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do privilégio.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Primeiramente, afasto tese defensiva de ilicitude da ação dos policiais por falta de mandado de busca e apreensão.

A Constituição Federal expressamente autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, como aquele em que há o flagrante delito, dispondo, em seu art. 5º, inciso XI, que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação

judicial".

De outro lado, o crime de tráfico, na modalidade "ter em depósito" substância entorpecente, é permanente.

No caso dos autos, conforme demonstrou a prova que, a seguir será analisada, o réu foi surpreendido pelos policiais civis em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao avistá-los, ele agiu de forma suspeita e indicativa de que estava cometendo tal ilícito penal, pois tentou empreender fuga, sendo, entretanto, abordado logo em seguida. Inicialmente, ele tentou evitar a diligência policial na sua residência, dizendo que não morava na comunidade, mas após ser delatado por outros moradores, os quais indicaram onde ele residia e depois que os policiais encontraram com ele a chave do referido imóvel, o réu admitiu morar naquele local, autorizou o ingresso dos agentes na residência e lá eles encontraram os entorpecentes descritos na denúncia.

Registre-se que o réu não refutou tais fatos, nem perante a Autoridade Policial, nem na audiência de custódia, onde não relatou qualquer abuso por parte dos policiais, nem em juízo, eis que se tornou revel.

Logo, não há como se reconhecer a ilicitude pretendida pela nobre defesa pela ausência de mandado de busca e apreensão.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Preliminar - Nulidade - Violação de Domicílio - NÃO VERIFICADO – O ingresso dos policiais na residência a priori foi franqueada pelo paciente, após denúncia anônima. Diante de tal contexto, é certa a situação de flagrante, não havendo falar em nulidade da prisão por violação de seu domicílio. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada". (TJSP. Habeas Corpus Criminal 2095991-37.2021.8.26.0000. Relator: Paulo Rossi. 12ª Câmara de Direito Criminal. J: 02/06/2021) g.n.

No mérito, a denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 05/06;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 07 e fotografia de fls. 08/09;
- 3) laudo de constatação de fls. 29/33 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 93/95, com resultado positivo para cocaína relação à substância apreendida.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu permaneceu silente.

Em juízo, também não exerceu a autodefesa, tornando-se revel.

O policial civil José Vicente Fessel, ouvido na fase extrajudicial (fls. 03) e sob o crivo do contraditório (gravação), disse que, na data dos fatos, foi com seu colega Mauro foram ao bairro Novo Horizonte e, quando entraram na rua que vai para a favela, viram quatro pessoas num conhecido ponto de tráfico. Ao notarem a presença da polícia, os quatro tentaram sair rapidamente, correndo. Dos quatro, conseguiram deter apenas o réu. Ele negou que residia na comunidade, mas alguns populares informaram, de forma reservada, que ele morava ali e indicaram onde era a casa dele. Em poder do acusado não foi encontrado nenhum objeto ilícito. Contudo, ele tinha uma chave do portão de uma das casas e com ela, conseguiram abrir o

portão do barraco onde os populares informaram ser a residência do acusado. Neste momento, ele admitiu que se tratava de sua residência e permitiu o acesso dos policiais ao seu interior. Na propriedade, próximo a um galinheiro, foram encontrados 22 “eppendorfs” de substância esbranquiçada, semelhante à cocaína, e outras 44 porções de substância amarelada, aparentando ser “crack”. Questionado sobre as drogas, o réu assumiu informalmente a posse e admitiu o destino mercantil. No mesmo sentido as declarações prestadas pelo policial civil Mauro Teixeira Nunes na delegacia de polícia (fls. 03) e nesta data (gravação).

Anoto que os relatos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER – j. 23/10/2018) g.n.

“Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.” (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª

Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 22 "eppendorfs" contendo cocaína e 48 porções de "crack", fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, o réu foi surpreendido pelos policiais civis em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e, ao avistá-los, tentou empreender fuga, sendo abordado logo em seguida. Inicialmente, ele tentou evitar a diligência policial na sua residência, dizendo que não morava na comunidade, mas após ser delatado por outros moradores, que indicaram onde ele residia e depois que os policiais encontraram com ele a chave do imóvel, o réu admitiu morar naquele local, autorizou o ingresso dos agentes na residência e lá eles encontraram os entorpecentes descritos na denúncia. Registro que o destino mercantil dos entorpecentes apreendidos ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência, mas também em razão da quantidade de drogas (22 "eppendorfs" e 48 porções de "crack"), incompatível com a situação de mero usuário e pelo fato de estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvção - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA

DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 105/106 e certidões de fls. 109/110).

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

A diversidade de drogas e a quantidade, embora esta seja significativa a ponto de indicar o tráfico, não fugiram à normalidade da espécie.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

As atenuantes não autorizam a diminuição das penas aquém do mínimo legal.

Inexistem agravantes ou causas de aumento de pena.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, possível aplicação do entendimento explanado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de "envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa" (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma

pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e repressão dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu LUCIANO DIAS BARBOSA a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestaria sobre sentença ora proferida no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos. Intime-se o(a) ré(u) do teor da sentença, bem como se dela deseja recorrer. Com a juntada do mandado, devidamente cumprido, dê-se vista à Defensoria Pública para eventual interposição de recurso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.